

1501514-60.2020.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Glaucio Roberto Brittes de Araujo

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... de usuários em perspectiva. A confissão e a função do réu no tráfico (ausente prova de efetivo comando e gerência na região), por outro lado, não condizem com a redução mínima.

Em suma, como tais fatores não foram considerados para aumento da pena na primeira fase, podem nortear a terceira. Sobre a temática, confira-se:

"EMENTA PENAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

4ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501514-60.2020.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501514-60.2020.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2178337/2020 - DISE-

DEL.SEC.GUARULHOS, 12554594 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS, 101/20/222 - DISE-

DEL.SEC.GUARULHOS, 2178337 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO JOSE DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Glaucio Roberto Brittes de Araujo

VISTOS.

RODRIGO JOSE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 21 de julho de 2020, por volta das 14 horas, na Rua Hélio de Souza, altura do nº 350, bairro Fortaleza, nesta cidade e Comarca de Guarulhos, nas imediações de estabelecimento de ensino e de local destinado à prática esportiva, vulgo "Turiba", trazia consigo e guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 63 (sessenta e três) invólucros contendo Cannabis Sativa L, substância vulgarmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 52,43g, e 410 (quatrocentos e dez) invólucros (ependorfs) contendo cocaína, com peso líquido de 226,92g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 16/17, Laudo de Constatação a fls. 19/25, e Laudo do Exame QuímicoToxicológico Definitivo a fls. 61/63).

O réu foi notificado (fls. 184) e apresentou resposta (fls. 189). A denúncia foi recebida (fls. 191/192). Não tendo ocorrido absolvição sumária, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

Em instrução regular, foram ouvidas duas testemunhas comuns à acusação e defesa e o acusado foi interrogado.

Superada a fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, em debates, a representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia, com aumento da pena pelo disposto no art. 40, sem o redutor, além de regime fechado, opondo-se à substituição por restritiva de direitos.

A Defesa, por sua vez, postulou a absolvição nos termos do artigo 386, VII do CPP e, subsidiariamente, fixação da pena no mínimo legal, atenuante da confissão espontânea, aplicação do redutor do parágrafo 4º, afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, III da Lei de Drogas, regime aberto e substituição por restritivas de direito, além dos benefícios da justiça gratuita.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal procede.

A materialidade está provada, conforme Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão, Autos de Constatação de Substâncias Entorpecentes e Laudo Pericial, cujas conclusões foram positivas para Cocaína e Tetrahydrocannabinol, e prova oral.

A quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas, a apreensão de dinheiro (R\$36,00), as circunstâncias da posse e a confissão evidenciam que o entorpecente seria fornecido a terceiros. A conduta corresponde, perfeitamente, ao tipo penal do art. 33, da Lei 11.343/06. A autoria é igualmente certa, diante dos depoimentos colhidos e da confissão.

O réu Rodrigo confessou plenamente a prática delitiva, negando apenas a propriedade das drogas localizadas no cano de PVC, que pertenciam ao gerente. Admitiu, contudo, que indicou o local para os policiais, a fim de ajudá-los. Destacou que está liberto do vício e que tinha obtido liberdade provisória em outra ocorrência. Alegou que estava há pouco tempo na função. A confissão encontrou sólido respaldo probatório. Vejamos.

O policial Fabrício afirmou que, em conhecido ponto de tráfico, avistaram o réu, o qual se evadiu para um matagal com uma sacola. Conseguiram detê-lo e encontraram uma boa quantidade de maconha e cocaína em porções em seu poder. Em um cano de PVC perto dele, acabou indicando o restante da droga. Salientou que não o conhecia e que ele confessou informalmente a traficância. Aduziu que, para chegar a essa viela

sem saída, é necessário passar por uma escola e uma pista de skate.

O policial Ricardo afirmou que avistaram o réu, em um conhecido ponto de tráfico, e ele tentou se desvencilhar da abordagem. Encontraram a sacola com drogas e ele mesmo desenterrou o cano de PVC, onde havia o restante do entorpecente. Destacou que ficaram sabendo por uma interceptação telefônica que havia venda de drogas enterradas em um cano de PVC. Declarou que ele confessou informalmente a traficância e que não o conhecia. Confirmou que o local fica perto de uma escola.

Como se percebe, os fatos narrados na exordial acusatória restaram devidamente comprovados. No dia referido, o acusado se postou no local dos fatos, um terreno baldio, atrás de uma pista de skate, a aproximadamente duzentos e quarenta metros da Escola da Prefeitura de Guarulhos Erico Veríssimo, conhecido ponto de venda de entorpecentes, com o objetivo de exercer o tráfico ilícito. Para tanto, trazia consigo uma sacola plástica contendo 125 (cento e vinte e cinco) eppendorfs de cocaína e 23 (vinte e três) invólucros de maconha, com pesos líquidos de 68,33g e 22,95g, respectivamente. Ademais, guardava, em um terreno baldio, dentro de um tubo de "PVC", 285 (duzentos e oitenta e cinco) eppendorfs contendo cocaína e 40 (quarenta) invólucros contendo maconha, com pesos líquidos de 158,59g e 29,48g, respectivamente.

Com efeito, observa-se que a confissão informal e judicial encontrou sólido amparo nas provas produzidas, enquanto a negativa da propriedade de parte das drogas acabou refutada pelo resultado da instrução. A confissão, suficiente para responder pelo tráfico, não permaneceu isolada e foi corroborada por várias declarações. Nenhum dado concreto a abalou. Não há que se falar, portanto, em eventual insuficiência, por seu valor relativo, da confissão judicial, já que esta, no caso dos autos, está amparada por vários elementos probatórios, mormente depoimentos harmônicos. Nesse sentido, transcreve-se lição de Guilherme de Souza Nucci: "(...) a confissão ganha qualquer outra prova. Até certo ponto ela as transcende; elemento no cálculo da verdade, ela é também o ato pelo qual o acusado aceita a acusação e reconhece que esta é bem fundamentada; transforma uma afirmação feita se ele em uma afirmação voluntária. Pela confissão, o próprio acusado toma lugar no ritual de produção da verdade penal". (Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., São Paulo: RT, 2012, p. 470).

Ademais, os policiais narraram, com detalhes, coerência e firmeza, a atitude suspeita do réu, a posse das drogas prontas para venda, a importância em dinheiro apreendida e a confissão espontânea, enquanto a defesa não soube relatar dinâmica diversa verossímil e não cogitou de motivo concreto para ser supostamente incriminado de forma aleatória e falsa. Cada testemunho judicial é corroborado pela prova oral do inquérito.

Não é crível, outrossim, que soubesse onde estava o restante da droga, justamente da mesma espécie e acondicionamento análogo, sem ter nenhum vínculo com as porções e sua comercialização. Não indicou suspeito e não forneceu dados para localização e identificação do suposto responsável, que certamente conheceria, já que sabia da existência do material no pvc e alegou disposição de ajudar os policiais. Nenhum outro traficante foi visto. Por fim, a quantidade maior apenas incrementaria a reprimenda e não afetaria a configuração do delito, que já se contenta com as porções que o réu portava.

No mais, aquela quantidade de maconha e cocaína não se destinaria apenas ao uso pessoal, sobretudo na via pública, em várias porções, acompanhadas de dinheiro. Não obstante os argumentos da Defesa, as provas são fartas e não era imprescindível a abordagem de destinatário da substância, embora conveniente. A medida poderia frustrar o resultado do flagrante, além de inviável ante a fuga dos presentes.

Além disso, não há razão plausível para desprezar as declarações de testemunhas

isentas, sob compromisso formal, inclusive acerca da confissão espontânea. Saliente-se que merecem crédito e são dotados de valor probatório determinante, em delitos de tal jaez. Nesse sentido, há farta jurisprudência: "O valor de depoimento testemunhal de policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.X (STF, HC nº 73.518-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.1996).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA FUNDAMENTADA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM TESTEMUNHOS PRESTADOS POR POLICIAIS. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. (...) 2. Não há óbice a que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu sejam considerados na sentença como elemento de prova amparador da condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, tal como na hipótese, em que a expressiva quantidade de droga apreendida - 24 (vinte e quatro) invólucros com crack - revela não ser o entorpecente destinado a consumo próprio. 3. Tem-se por adequado o regime fechado para o início do cumprimento da pena corporal de 5 (cinco) anos aplicada ao paciente pelo tráfico de drogas, dado o estabelecimento da pena-base acima do mínimo legal em conta do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas, não se olvidando a quantidade de entorpecente que trazia consigo. 4. Ordem denegada." (STJ, HC n.º 223086 / SP; 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.11.2013).

E o decreto condenatório não se baseia tão somente nos dados do inquérito ou palavra de policial. No caso concreto, todos os elementos probatórios harmonizam-se, inclusive aqueles obtidos na fase judicial, sendo certo que o magistrado pode utilizar todos na formação de seu convencimento. Ainda que assim não fosse, não há óbice à valoração, embora relativa, dos elementos colhidos na fase de investigação para fundamentar eventual decreto condenatório, porquanto a vedação legal é no sentido da impossibilidade de condenação lastreada exclusivamente em tais provas, nos exatos termos do art. 155 do CPP. Neste sentido, é a jurisprudência:

"(...) Mostra-se válida a condenação imposta com auxílio de dados obtidos na fase inquisitorial se tais estão em consonância com o apurado em juízo. O desprezo ao que se produziu na fase investigativa não é possível por força do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, adotado em nosso ordenamento. Portanto, ainda que tenha a princípio menor valor o elemento produzido no caderno inquisitivo, por força do disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, não pode tal ser afastado de pronto. No caso dos autos a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, confirma e corrobora a prova produzida tão somente no inquérito policial. Assim a prova deve ser vista como um todo, não se considerando o lugar onde foi produzida, mas o valor probante, estando garantido os direitos constitucionais do réu, conforme acima exposto". (TJ/SP, Apelação nº 0039765-66.2010.8.26.0506, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Lauro Mens de Mello, j. 28/04/2016).

Nessa ordem de ideias, os relatos dos policiais foram coerentes nas duas fases processuais, minuciosos, harmônicos, seguros e condizentes com os elementos sensíveis da infração. Não havia motivos plausíveis, a propósito, para incriminar falsamente um desconhecido. Também não surgiram indícios de que as drogas pertencessem a outrem, de vício ou de equívoco no flagrante.

No mais, em delitos de tráfico, as evidências são determinantes para elucidação do vínculo subjetivo entre o agente e as drogas e de sua destinação, sendo inviável prova concreta e cabal do seu pensamento. De outro lado, não se alegou pronta e

espontaneamente e não ficou evidenciado que toda aquela droga apreendida seria consumida.

De qualquer sorte, a quantidade, a forma de acondicionamento da droga, a importância em dinheiro, a confissão e as circunstâncias da ação revelaram sobrejamente a destinação a terceiros. É comum até mesmo o usuário, aliás, comercializar, sobretudo para sustentar o vício. Incabível, pois, eventual tese de insuficiência de provas ou desclassificação para art. 28, da lei.

O acusado é imputável e praticou os atos típicos descritos na norma penal. Justificativas relativas à situação econômica ou dependência, ainda que, em tese, tivessem contribuído para a traficância, não são dirimentes da ilicitude ou da culpabilidade. Não justificam a despicienda ofensa ao bem jurídico.

Finalmente, nenhum álibi restou comprovado de maneira inequívoca e nenhuma excludente ficou configurada. Não pairam dúvidas sobre o liame subjetivo entre o réu e as drogas encontradas e sobre a finalidade de fornecimento a outrem.

No mais, restou comprovado que a mercancia era realizada perto de estabelecimento de ensino e de local destinado à prática esportiva. Com efeito, o acusado foi flagrado em viela, nas imediações da Escola da Prefeitura de Guarulhos Érico Veríssimo. As testemunhas informaram que, para chegar a essa via sem saída, é necessário passar por uma escola e uma pista de skate (240m de distância, conforme croqui fls. 78). Assim, presente o risco condizente com a aplicação da causa de aumento, tendo em vista o acesso fácil dos estudantes e menores às drogas. Embora a norma não exija horário de aula ou venda direta a aluno, é certo que a ocorrência se deu em período compatível com movimento ou acesso à escola. De qualquer modo, o tipo prescinde da proximidade de menores ou outro fator específico, contentando-se com o perigo, como fruto do recurso comum à técnica legislativa de tal jaez.

Portanto, comprovada a materialidade delitiva e evidenciada a autoria do tráfico privilegiado, ante o complexo probatório robusto e coerente produzido nos autos, impende apreciar a dosimetria da pena fixando-a no patamar suficiente e necessário à reprovação do delito.

Bem sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, tendo em vista a primariedade (fls. 88/89), na primeira fase, fixo a pena-base consistente em 5 (anos) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A quantidade já é considerada na configuração da destinação a terceiros e no emprego de redução menor na terceira fase, não sendo usada aqui para majoração, sob pena de bis in idem.

Na segunda fase, incidem as atenuantes confissão e menoridade relativa, que, contudo, não possuem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, nesse lanço, nos termos da jurisprudência consolidada.

Na terceira etapa, incide a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06 em 1/6, levando a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, pois a atividade ilícita do tráfico estava sendo desenvolvida pelo réu nas imediações de estabelecimento de ensino, fato incontroverso e evidenciado nos autos.

Por outro lado, tendo em vista a primariedade do réu e a ausência de indícios de envolvimento em organização criminosa, adota-se a causa de diminuição do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 em 1/3, perfazendo 3 anos e 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 388 dias-multa. Da mera quantidade de drogas, exclusivamente, não se extrai filiação a grupo criminoso ou mesmo dedicação permanente à atividade ilícita organizada. Embora comum nestes casos, seria necessário elemento concreto convincente a respeito do vínculo. Sequer foi obtida, outrossim, sob o crivo do contraditório, prova da condição de integrante de grupo especializado ou de encargo

duradouro e relevante em tal atividade. Assim, considerando a quantidade e espécie de parte do entorpecente (cocaína), mais lesiva à saúde do que outras, de um lado, e a função de pequeno varejo, de outro, a reprimenda é reduzida no patamar intermediário, perfazendo 3 anos e 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 388 dias-multa.

À míngua de critérios seguros e explicitamente estabelecidos para a aplicação do art. 33, par. 4, da Lei 11343/06, o art. 42 do referido diploma legal deve orientar o patamar daquela redução. Restringir este preceito à fase do art. 59, do Código Penal, a par de despicendo, criaria distinção injustificada em relação a outros delitos, na primeira etapa de dosimetria da pena, e não permitiria solução eficaz para a controvérsia acerca dos critérios de redução da terceira fase.

Por conseguinte, no caso em apreço, ante a quantidade, a variedade e a natureza de parte da droga, não se exige a redução máxima, estando preservado o prudente arbítrio do julgador. A propósito, a lei estabelece somente que as penas “poderão” ser reduzidas. Além disso, entende-se que por se tratar de causa de redução como simples benefício – que já pode ir aquém do mínimo legal – e não de dosimetria da primeira fase, não se adota a pena menor em perspectiva (diminuição máxima) como regra. Muito pelo contrário, a legislação recente destinou-se ao agravamento da coibição, da repressão e da resposta penal para o tráfico de entorpecentes, sendo ilógica e dissociada do princípio da razoabilidade a exigência peremptória da diminuição máxima da pena, que a levaria a um patamar muito inferior ao da lei antiga.

Segundo exegese sistemática e teleológica, o percentual de diminuição deve ser escolhido de acordo com o caso concreto e a especificidade do potencial lesivo da conduta, como possível número de usuários em perspectiva. A confissão e a função do réu no tráfico (ausente prova de efetivo comando e gerência na região), por outro lado, não condizem com a redução mínima.

Em suma, como tais fatores não foram considerados para aumento da pena na primeira fase, podem nortear a terceira. Sobre a temática, confira-se:

“EMENTA PENAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso que espera a absolvição. Impossibilidade. Provas dos autos que evidenciam a autoria e materialidade delitivas de forma robusta. Confissão judicial e palavras dos PMs. Condenação mantida. Possibilidade de redução das penas. Ausência de indicativos de dedicação ao crime. Privilégio aplicável aos réus, primários. Redutor na fração de um quinto, considerada a quantidade de entorpecente apreendida. Regime inicial intermediário suficiente para a reprovabilidade do delito. Apelos providos em parte para redução das penas. (TJ/SP, Apelação n.º 0001273-25.2018.8.26.0635; 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, j. 19/08/2020).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENAS-BASE FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. PACIENTE RAFAEL. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. UTILIZAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E PARA A NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ANÁLISE PREJUDICADA. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO, DE OFÍCIO” (STJ, Habeas Corpus nº 317.461-SP, Sexta Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 26.05.2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. VERIFICAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. 10 KG DE COCAÍNA. SUPOSTA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DO DECISUM A QUO. ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA ORIGEM. 1. Na dosimetria do delito de tráfico de drogas, configura bis in idem utilizar a

gravidade e quantidade da droga apreendida para, a um só tempo, fixar a pena-base acima do mínimo legal e afastar a aplicação da diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 2(...)" (STJ, AgRg no Recurso Especial nº 1.491.994-GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19.05.2015).

Não há outras causas de aumento ou de diminuição, mantendo-se a pena no patamar fixado. Não há outras causas de aumento ou de diminuição, mantendo-se a pena no patamar fixado.

Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, tendo em vista a quantidade da pena, a natureza do crime (sem violência ou ameaça) e as circunstâncias favoráveis do artigo 59, do CP. Por se tratar de tráfico de drogas privilegiado, cumpre observar decisões recentes dos Tribunais Superiores no sentido de que o referido crime não é hediondo e enseja regime compatível com a quantidade da pena. Sobre a temática, confira-se:

"EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDIVIDUAL E COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DIRETRIZES REGISTRADAS PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641 (PLENO). PRECEDENTES DESTES TRIBUNAL DA CIDADANIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, LEI N. 11.343/2006). TRÁFICO. DEFINIÇÃO LEGAL (ART. 112, §5º, LEI N. 7.210/1984). CRIME NÃO HEDIONDO. CONECTIVOS LÓGICOS EM RAZÃO DESSE RECONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E SÚMULAS DE JURISPRUDÊNCIA. FORÇA NORMATIVA. ESTUDO DO INSTITUTO CONECTAS E DADOS ESTATÍSTICOS QUE CONFIRMAM O DESCUMPRIMENTO REITERADO PELO TRIBUNAL IMPUGNADO. DESRESPEITO AO SISTEMA DE PRECEDENTES. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE. ISONOMIA DO JURISDICIONADO. BUSCA À RACIONALIDADE PUNITIVA. PREDICATIVO ÍNSITO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME PRISIONAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE". (STJ, HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1) - Decisão Monocrática- Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).

Ademais, tal conclusão também decorre da Lei de Execuções Penais, com as alterações trazidas pelo pacote anticrime (Lei n.º 13.964/2019), mais precisamente da redação art. 112, § 5º da LEP: "Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006."

Com todo respeito ao inconformismo e razões normalmente invocadas pelo MP, suposto descabimento da via eleita para pretensão prevenção de interesse coletivo contra legítimo entendimento predominante no TJSP e concepção conferida à proporcionalidade não são suscetíveis de reavaliação pelo juízo de primeiro grau, sendo contraproducente, ademais, a prolação de decisão em sentido oposto, que desafiaria recursos e eventual reclamação em detrimento do resultado profícuo do processo e da economia processual.

Preenchidos ainda os requisitos do art. 44, do CP, à luz da primariedade e da pena aplicada, e sendo socialmente recomendável, concede-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena e prestação pecuniária de um salário-mínimo a uma entidade com função social, especificadas oportunamente pelo juízo da execução.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO o acusado RODRIGO JOSE DA SILVA, qualificado nos autos, no cumprimento da pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação gratuita de serviços à comunidade pelo prazo da pena e prestação pecuniária de um salário-mínimo a uma entidade com função social, especificadas oportunamente pelo juízo da execução,

além do pagamento de 388 dias-multa, no valor unitário mínimo, com atualização monetária, como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III ambos da Lei nº 11.343/06.

O réu poderá apelar em liberdade, pois concedida a substituição da pena privativa por restritiva de direitos. Expeça-se alvará de soltura clausulado, em favor do acusado, com urgência.

Transitada esta em julgado, far-se-á a necessária comunicação ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para o fim previsto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Declaro o perdimento do dinheiro em favor da União, ante as evidências da relação com o tráfico, e determino a incineração da droga apreendida.

Custas e despesas processuais pelo sentenciado, respeitada a gratuidade.
P.I.C.

Guarulhos, 02 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA